

1500546-84.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RÉU REINCENTE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500546-84.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500546-84.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SUELI APARECIDA LOPES

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

SUELI APARECIDA LOPES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 08 de fevereiro de 2021, por volta de 11:15 h, no cruzamento entre a Rua Ângelo Raspante e Rua Pedro A. Filho, nesta cidade e comarca de Marília, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 3,19 gramas de cocaína, divididos em sete microtubos, e 13,09 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em sete porções (fls. 10/11, fls. 21/23 e fls. 131/133).

A ré foi presa em flagrante delito e a prisão foi convertida em prisão preventiva (fls. 79/81). Foi notificada e citada (fl. 178) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 165/168). A denúncia foi recebida em 19/3/2021 (fls. 182/184). Houve, ainda, na mesma ocasião, a determinação para instauração de incidente de sanidade mental, com o qual o Ministério Público manifestou concordância (fl. 176).

Na audiência de instrução virtual, realizada em 13/4/2021, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e a ré foi interrogada (fls. 221/223).

O laudo médico legal, confeccionado no incidente de sanidade mental (em apenso), foi juntado aos autos (fls. 309/315 e fls. 316/322).

Em memoriais (fls. 331/334), o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal, a agravante da reincidência na segunda fase e, na terceira fase, que seja rechaçada a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Apontou que em virtude da reincidência específica deve ser fixado o regime inicial fechado.

A Defesa por sua vez, às fls. 338/344, requereu a absolvição porque embora apreendido entorpecente, a prova do comércio ilícito é frágil e a dúvida deve beneficiar a ré. Diante da ausência de provas quanto aos atos de comércio a absolvição é de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, não havendo outros indicativos, deve-se optar pela desclassificação para o crime de posse para uso próprio.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

Inicialmente, cumpre registrar a conclusão do laudo pericial acerca da dependência toxicológica e sanidade mental no qual a acusada foi considerada "(...) sob a ótica médico-legal psiquiátrica imputável para o delito descrito na denúncia".

No mais, a existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 21/23), laudo químico-toxicológico (fls. 131/133), este último atestando a natureza das substâncias apreendidas, e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

A testemunha Marli Ribeiro Augusto, policial civil, declarou que no dia dos fatos ela e seu colega Fábio receberam uma informação de que, no local descrito na denúncia, conhecido pela venda de entorpecentes, havia uma mulher chamada Sueli vendendo drogas. O entorpecente estava escondido embaixo da roda dianteira de um carro velho, estacionado em uma rua de terra. Quando se aproximaram, puderam notar que a referida Sueli era a ré, já conhecida pelos policiais por outras ocorrências de tráfico. Quando ela notou a presença dos policiais jogou um "pino" rosa no chão, com cocaína. Em revista pessoal encontraram com ela a quantia de R\$25,00. Ao vistoriarem o carro mencionado na denúncia, eles encontraram uma "muca" onde havia mais seis "pinos" de cocaína, também da cor rosa, e sete porções de maconha. No local, a ré permaneceu em silêncio. Na delegacia, disse que o "pino" de cocaína era para consumo. A testemunha esclareceu que o local é reduto de vários traficantes e é normal os traficantes esconderem drogas ali.

A testemunha Fábio Portaluppi Marinho, policial civil, afirmou que ele recebeu a informação de que no local dos fatos havia uma mulher de nome Sueli, recém egressa da prisão, que estaria traficando drogas. Ela estaria usando um cachecol e vendendo as drogas, que estavam escondidas embaixo do pneu dianteiro de um carro velho. Foram até o local e visualizaram a ré, aproximadamente seis metros do carro velho. Ao realizarem a abordagem a ré Sueli dispensou um "pino" rosa contendo cocaína. Em revista pessoal encontraram com ela R\$25,00. No local indicado como esconderijo das drogas havia mais sete "pinos" de cocaína, também da cor rosa, além de seis porções

de maconha. Um outro homem que estava por ali foi abordado mas nada de ilícito foi encontrado. No local, a ré não declarou nada. Na delegacia ela disse que era usuária de drogas e que fazia "programas". Por fim, esclareceu que o local é reduto de várias apreensões.

A testemunha de defesa Ordalia Peres de Almeida Mancini afirmou que é amiga e vizinha da ré e a conhece há vinte anos. Sabe que ela estava presa e, quando saiu, passou três dias na casa da filha e depois foi morar na rua. Ela levou a ré para sua casa, para tomar um banho e comer, e depois ela foi presa. Disse que já presenciou a ré sendo agredida por "ratear" uma biqueira.

A ré Sueli Aparecida Lopes, interrogada, afirmou que é usuária de drogas e já fez diversos tratamentos, inclusive no CAPS. Declarou que após sair da prisão, passou dois dias na casa da filha e se sentiu mal, entendendo serem sintomas de abstinência. Voltou a fazer "programas" e, na noite anterior aos fatos, ganhou R\$30,00. Comprou um "corote" por R\$5,00 e quando passava na frente de uma "biqueira" um rapaz disse que havia chegado cocaína "da boa". Ganhou uma porção, que consumiu no local, pediu mais uma porção, que iria pagar, momento em que a polícia chegou e a abordou. Negou estar traficando drogas. Afirmou que estava calor esse dia e que não usava cachecol.

Apesar da negativa da acusada, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que ela era a proprietária do entorpecente e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) as informações prévias descrevendo que no local, conhecido como ponto de traficância, havia uma mulher de nome Sueli comercializando drogas; b) a convergência da denúncia que apontava o esconderijo da droga, qual seja, pneu dianteiro de um carro velho, onde os policiais lograram êxito em encontrar a "muca" contendo droga; c) a natureza diversificada das drogas apreendidas, ou seja, 7 porções de maconha e 7 microtubos de cocaína, notadamente embaladas individualmente, prontas para serem vendidas a terceiros; c) o fato da ré dispensar microtubo de cocaína exatamente igual àquele apreendido no esconderijo junto ao carro velho.

Ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos no sentido de que receberam denúncias prévias apontando o local e o nome da mulher que estava comercializando entorpecente ali, havendo convergência inclusive em relação ao local utilizado como esconderijo das drogas, embaladas individualmente, de forma a caracterizar a venda a terceiros.

Nota-se que diante de elementos tão precisos, a menção a roupa ou acessório porventura utilizado pela sentenciada na ocasião torna-se insignificante.

Outrossim, ainda que a quantidade de entorpecente apreendida seja pequena, o fato é que mesmo sendo usuária, tal situação, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ela faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Ainda, no que concerne à tese defensiva, cabe registrar que a condenação pelo tráfico, tal como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia.

A situação dos autos é típica do comércio ilícito e não do simples usuário, salientando que é cada vez mais comum nas referidas abordagens serem encontradas em poder do autuado poucas porções, ficando a maioria das porções acondicionada em locais próximos.

No mais, a aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 não comporta acolhimento, já que a ré é reincidente em crime doloso, inclusive por condenação ao tráfico ilícito de entorpecentes.

A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no dispositivo legal mencionado acima, haja vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o réu seja primário. E por ser a reincidência apenas um dos requisitos que impede a incidência do benefício penal, não sendo elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em bis in idem.

No mesmo sentido:

“(...) Na terceira etapa, nada há a alterar. A aplicação da causa de diminuição era inviável. Trata-se de réu reincidente. Nesse sentido, importante observar a consolidação do entendimento jurisprudencial segundo o qual a afirmação da reincidência como agravante e a vedação da causa de diminuição pelo mesmo motivo não implicam violação da garantia do ne bis in idem. Segue jurisprudência: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RÉU REINCIDENTE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] V - A reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).(...)”. (Apelação nº 1501544-34.2019.8.26.0599, Relator Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 18/11/2020).

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Verifica-se que a ré possui condenação transitada em julgado (fls. 41/42), que caracterizará a reincidência na próxima fase. Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 em razão da acusada ser reincidente (processo nº 0019909-10.2016.8.26.0344 - 1ª Vara Criminal de Marília/SP - fls. 41/42), totalizando uma pena provisória de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes da pena.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a ré é reincidente.

Mantenho, desta forma, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Pelas condições econômicas da sentenciada, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO a ré SUELI APARECIDA LOPES, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado, considerando que pesa em desfavor da ré a reincidência específica (processo nº 0019909-10.2016.8.26.0344 - 1ª Vara Criminal de Marília/SP - fls. 41/42) e que cometeu o delito durante o cumprimento de pena no regime aberto (audiência admonitória em 24/11/2020 - fl. 41), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim a acusada deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência da ré, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

Em razão da decretação de prisão preventiva em desfavor da acusada (fls. 79/81) e sua manutenção às fls. 232/233, fls. 252/253, fls. 265/266, fls. 280/281, fl. 293 e fls. 305/306, bem como pela apreensão de entorpecentes altamente nocivo (cocaína), de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerada durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória, mantenho a prisão preventiva da ré, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se a ré no presídio em que se encontra recolhida.

Em face da condenação supra, a sentenciada arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Outrossim, em razão da origem ilícita do dinheiro apreendido nos autos (fls. 10/11) e depositado à fl. 134, decreto a perda do numerário e a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da citada lei, oficiando-se.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e intime-se a Defesa pelo DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA